

第二部分 宪法基本权利

宪法基本权利总论（概念、特征、主体、分类、保障、效力）

宪法基本权利分论（按照人权的规范分类，详细讲解各种基本权利的涵义与适用）

基本权利总论

（一）权利理论概要

法律现象的构成：逻辑、社会事实与价值

市场经济催生各类经济法

任何规范背后都有价值预设

EX: 故意杀人罪后 → 生命权价值至高

（1）权利的逻辑构成（法规范上的表现形式）

分析实证法学家

霍菲尔德的权利“原形式”理论

逻辑论/原子主义 → 权利有四种形式

权利的完整形式：请求权（Claim）——义务（Duty）

自由（privilege）——无权利（no right）

能力（power）——责任（liability）

豁免（immunity）——无能力（disability）

将人根据请求决定做/不做

义务人不得要求权利人做/不做

不能干预权利人自由 EX: 宪法中公民有言论自由

根据自己意愿去做/不做

自主决定创立/消灭/变更某种法律关系

义务人只能消极地承受

EX: 遗嘱指定继承

（2）权利的社会事实要素

在社会“大场景”下考察权利的本质

特定的利己

耶林首创的“利益说”最具影响

19世纪德国法学家“为权利而斗争”

权利的本质——法律所欲保护的利益

权利在法律规范中只是一个符号，背后隐藏着法律所欲保护的利益

（3）权利的价值要素

价值：评价标准

按照自然法学的标准

自由、平等

法律、权利的终极价值取向可归结于“正义”

以上权利的三要素中，逻辑形式是法律学的特有视角

而社会事实因素与价值因素是权利的本质学说，其他学科亦可以获得这种认识

(二) 宪法基本权利的概念

1. 人权(美)、基本权利(德)、基本人权(日)、宪法权利

2. 双重要素:

(1) 针对国家的权利

个人是基本权利的主体 “个人——国家”之法律关系

公法上的权利 私人主体一般不会侵犯宪法权利 国家会侵犯个人权利 → 公法内来国家

(2) 固有的权利、最起码的权利

人之为人应有的权利 ----- 宪法权利的核心要义

(三) 宪法权利的基础原理(核心价值)

1. 功能: 在特定的宪法秩序中解决人权保障之正当性问题

人权体系的最高价值

所有的人权都可以视为基础原理的具体化

推定新权利的实质性论据

2. 发展过程

近代宪法: 天赋人权

浓厚自然法色彩

现代宪法: 受到实证主义、科学主义的影响 自然权利的实证化

个人自由(美国) 人性尊严(德国)

日本: 公民追求幸福生活的权利是宪法的基础原理

现代西方人权理论的两种进路 (美 vs 德)

3. 个人自由原理的涵义: 个人主义权利论

第一, 个人的自治能力 (自我选择和自我决定) ex: 隐私权 → 避孕

第二, 个人在行使其自治能力时被给予的平等对待和对于个人之尊重。

第三, 个人自由的绝对化——哲学上的个人主义立场

中国: 集体主义 在集体和个人冲突时优先考虑个人利益

大国崛起 vs 小国尊严
中西权利观念冲突

权利的
核心和
最高价值

4. 人性尊严的涵义: 自我决定是核心 德

第一, 个人自治 (Personal Autonomy) 与自我决定 (Self-determination)

第二, “把人当作目的”之人性观 (康德)

人不能被当作手段和工具

德国禁止使用测谎仪

Commented [1]: 你行动时, 永远要把人性, 无论是你自己的人性, 还是他人的人性, 同时视作目的, 而不仅仅是一种手段。

第三, 个人承担责任、受到道德义务、社会责任约束

人格主义权利论

人格人的存在, 是以多种样态而存在, 在各种共同体之中而存在

平衡个人与共同体的关系

5. 两者之间的区别

和中国不同: 中国并不优先考虑个人而是优先考虑集体

现代西方两种人权理论之典范

个人自由原理强调 绝对的自由

人性尊严原理注重 个人自由与社会关系的协调, 强调个人承担道德、社会责任

案例: 小猪漫画案件判决

美国认为公众人物享有公共资源, 其名誉权和隐私权受到约束

美国最高法院主张不受约束的“言论自由”

德国宪法法院强调“有限度的言论自由”, 承担社会责任, 不得侵犯人的尊严

思考: 中国宪法上应当确立怎样的人权基础原理?

集体利益优先

义务本位的深刻影响 个人主义是中国传统文化的盲区

市场经济推进增强对个人利益的重视

(四) 基本权利的特征

1. 固有性和法定性

固有的人权: 先于国家、先于宪法的权利

(生命权、人身自由、思想自由) 并非由国家所赋予

法定的人权: 法律所创设的权利 社会权、福利权 取决于国家的经济、社会文化

依靠国家的财政

劳动保障

2. 不受侵犯性和受制约性

(1) 不受侵犯性是宪法的价值宣示, 各国宪法中均有“不受侵犯”、“受宪法保护”等表述

(2) 不受侵犯并不意味着不受制约, 大多数权利均须受到制约

(3) 权利受到制约的类型

无界限的基本权利——纯粹的精神、思想领域的权利。如信仰自由、思想和良心自由

法律只对人的行为构成调整，在法律上，只有人的行为才是有意义的

基本权利的内在制约——权利的内涵、外延存在于权利自身的界限之中

其本身的性质决定了权利的行使不得侵害其他主体放入权利

言论自由 v. 他人的隐私权

基本权利的外在制约——

以权利的外在因素限制权利范围，公共利益对财产权、经济自由的限制

例如：宪法上对私人财产的征收、征用

但也要进行利益衡量

权利的边界在于他人权利和公共利益

征收和征用制度：拆迁时与居民协商不成采取强制措施
私人财产神圣不可侵犯

3. 普遍性和特殊性

普遍性：

人权的固有性，人之为人的权利，超越国界、阶级、种族等一切外在条件的人权

特殊性：

人权中法定的社会权、福利权等，因经济文化条件的不同而不同

(五) 基本权利的主体

1. 个人

最基本的主体

关于堕胎，胎儿是否是一个主体
而非公民 中国国家观念决定

2. 法人与非法人组织

不享有人性尊严、人身自由、生存权等权利

3. 其他特殊主体：宪法特殊保护的主体——妇女、儿童、老人、母亲 外国人的政治庇护权

(六) 基本权利的保障模式

1. 直接保障模式（绝对保障模式）

宪法予以直接保障，权利具有“宪法效力” 议会立法不得限制基本权利

美国宪法

2. 间接保障模式（相对保障模式）

权利由宪法规定，但宪法承认法律对其加以限制的可能性

基本权利具有“法律效力”

如果没有立法，宪法权利就“束之高阁”，不能在司法中直接适用。
不过制定法律要依据宪法

二战以前的欧洲、德国魏玛宪法、日本明治宪法

“非依法律不得限制”、“在法律的范围内受到保障”

“法律保留”原则 ^{仅限制人身自由一定要有全国人大常委会制定的法律规定}

3. 混合保障模式

自由权具有宪法效力，宪法条文可直接适用

ex: 中国的劳动权、受教育权
社会权需要立法机关制定法律予以具体规定/纲领性权利/立法委托

（七）基本权利的效力范围

1. 针对国家的效力：

保障自由不受国家侵害

防御权效力——消极地不受侵害

保护义务：保护在私法关系中不受侵害

宪法加持民法，对宪法客观价值的保护

制度性保障：如大学自治和学术自由

透过组织和程序的保障：程序基本权

ex: 在作出不利决定前要告知我/允许我为自己辩护

2. 第三者效力

辐射效力

基本权利的客观价值秩序辐射民法领域

范围：重要的自由权（言论/名誉）

条件：向民事领域的“辐射”，从而构成对民事主体（第三者）的限制

媒介：民法中的概括性条款

（不能直接适用宪法）→ 用公序良俗解释 从而从宪法中的自由权概括进去
宪法中的言论自由是针对国家 → 抽象出来，作为主体，言论自由内在任何情况下都应受保护。以此将宪法价值引入民法

3. 保护义务理论中的基本权利对私法关系的效力问题

（1）原则上，基本权利不具有针对私法关系的直接效力

首先用民法/刑法去裁判。
宪法只是补充

(2) 私人关系中的基本权利侵害，首先适用具体的法律规定予以保护：民法、行政法、刑法

(3) 当出现立法保护不足时，法官有义务解释宪法基本权利条款，或者提起合宪性审查

立法保护不足：没有立法，或者立法有瑕疵，可以解释基本权利条款条偶填补漏洞。如 1954 年的德国夫妻分割财产案。
立法违宪，提交给宪法法院

(4) 某些具有“对世权”性质的基本权利（如人身自由/财产权），如果宪法明确规定，私人可主张请求权，可以直接适用于私法关系。
如，基本法：限制劳工结社自由的契约无效。

对世权的主张 → 二者缺一不可
可直接适用
宪法情况
宪法中明文规定的。

中国宪法：公民的宗教信仰自由，不受任何国家机关、社会团体和个人的限制。

(5) 私法关系提起的宪法诉愿，是对司法机关不履行保护义务的请求权。
德国：终审后认为判决侵犯了我的基本权利关系（违宪），向宪法审查机构（宪法法院）提出申诉，请求审查相关行为的合宪性

宪法诉愿提起的条件：用尽了所有的法律救济程序，当事人认为，基本权利仍然未得到救济。

案例：吕特案件

民事主体之间的纠纷：言论自由与名誉权之冲突

客观价值秩序：基本权利的辐射功能 以民法中的“公序良俗”条款为媒介

思考：中国的齐玉苓案件是否属于“第三者效力”？
受教育权受到侵犯，如何理解其内涵？
受教育的机会（自我选择决定的人格权）
宪法的司法化只能是违宪审查 → 但在中国只能由全国人大及常委会来

(八) 宪法基本权利的分类

1. 古典分类

人权与公民权 来自法国《人权宣言》
（人权与公民权宣言）
延伸：固有权——国民权——公民权（政治权 → 成年后）
二者之间（未成年）

2. 人权的代际分类

国家对未成年人的照顾，如受教育权

精神人权时。

第一代人权：自由权、平等权 形式平等

第二代人权：社会权 要求国家采取积极行动保障公民基本物质生活（个人）

第三代人权：民族、国家的生存权与发展权 中国提出。主体是民族国家（集体）不是法学上的权利。

3. 规范分类：
宪法分论

自由权 平等权 社会权 政治权利 救济权

